

1500841-44.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... por furto, porte ilegal de arma, roubo e tráfico de drogas, sendo procurado pela Justiça (fl. 11).

Em juízo, disse que a acusação é, em parte, verdadeira. No dia dos fatos estava na Avenida Cambuí, acompanhado do filho, e, ao ser abordado, confessou ser foragido da Justiça. Foi colocado na viatura na parte traseira, e o filho, no banco da frente, deslocando-se até sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquários

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1500841-44.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500841-44.2022.8.26.0617 2022/000578

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALEXANDRE BURGARELLI LOURENÇO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

CARLOS ALEXANDRE BURGARELLI LOURENÇO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, porque, segundo narrou a inicial, no dia 22.06.2022, no período noturno, na Rua Hilário Santana, altura do nº 70, Sítio Bom Jesus, nesta cidade e comarca, possuía e ocultava uma arma de fogo com numeração suprimida, da marca Luger/Sarsilmaz Kilinç, de calibre 9 mm, municiada com 06 cartuchos íntegros, além de outro carregador com mais 05 cartuchos e outros 50 sobressalentes, e uma pistola de airsoft, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia em 06.07.2022 (fl.76), o réu foi citado pessoalmente (fl. 108), apresentando defesa (fls. 99/102).

Ratificado o recebimento da denúncia (fl. 109/110), foi colhida a prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual gravado em arquivo digital).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia, pugnando pela fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, considerando as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência, agravante que deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, não fazendo o réu jus a qualquer benesse legal, determinando-se a destruição da arma de fogo, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10.826/03 (fls. 659/661).

A defesa, a seu turno, buscou, preliminarmente, a nulidade do auto de prisão em flagrante e das provas produzidas, pois houve violação do domicílio do acusado, tendo em vista a ausência de mandado judicial e não ocorrência de flagrante delito, devendo a denúncia ser rejeitada, e, no mérito, a absolvição, nos termos do artigo 386, V e VI, do Código de Processo Penal, haja vista a inocorrência de lesão a bem jurídico e a não comprovação pelo laudo pericial do potencial lesivo do simulacro de arma de fogo e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o artigo 12 da Lei nº 10.826; que sejam consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a imposição de regime inicial diverso do mais gravoso; detração dos 122 dias em que permaneceu preso preventivamente (fls. 668/698).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

A denúncia fora regularmente recebida (fl. 76), sendo após resposta à acusação ratificada esta decisão (fls. 109/113), estando portanto prejudicado o pedido de sua rejeição.

A alegação de nulidade da busca e apreensão exige aprofundado exame do caderno probatório e da prova oral, razão pela qual será decidida após sua análise.

O réu, interrogado perante a autoridade policial, declarou que havia acabado de sair de sua residência na companhia do filho com o veículo Fiat Uno, sendo abordado por policiais militares. Confessou aos policiais que mantinha sob sua guarda em casa um simulacro de arma de fogo, utilizado em treinos. Ao ser novamente indagado, admitiu que uma arma estava escondida em outro veículo, de propriedade de sua irmã, estacionado na garagem, tendo adquirido o armamento de pessoa desconhecida por R\$...4.000,00 para segurança familiar. Já foi preso e processado por furto, porte ilegal de arma, roubo e tráfico de drogas, sendo procurado pela Justiça (fl. 11).

Em juízo, disse que a acusação é, em parte, verdadeira. No dia dos fatos estava na Avenida Cambuí, acompanhado do filho, e, ao ser abordado, confessou ser foragido da Justiça. Foi colocado na viatura na parte traseira, e o filho, no banco da frente, deslocando-se até sua residência. A chave da casa estava no seu carro, que foi guiado por um policial, sendo usada pelos agentes para ingressar na residência sem nenhum acompanhamento. Os policiais localizaram a arma, que não funcionava mais. O filho foi deixado com sua mãe e foram para a delegacia. A casa era do seu irmão, que a alugava, estando vazia no momento. As armas eram suas, ressaltando que utilizava o simulacro para esporte. Acredita que o endereço da sua casa constava na denúncia, sendo conhecido pelos policiais, e que não houve nenhuma violência na abordagem policial. Perguntado pelo juiz acerca da confissão em sede policial acerca da localização das armas, disse que realmente confessou, asseverando que falou para os policiais quando estava na viatura que havia arma na casa. Comprou a

arma há 04 anos, para proteção da família (arquivo digital- fl. 595).

O policial militar LEONARDO RIBEIRO IZAQUIEL consignou que, no dia dos fatos, recebeu informação que o réu estava em um Fiat Uno, nas imediações do Bairro Bom Retiro, sendo localizado na Avenida Cambuí. Ao ser abordado, o acusado confessou que era procurado pela Justiça, estando em sua companhia do filho de 02 anos, motivo pelo qual foram até a residência do réu deixar a criança, sendo informados pelo réu que na casa havia uma arma na garagem, no banco de um veículo Fiesta, de propriedade de sua irmã. O réu franqueou a entrada na residência, fornecendo, inclusive a chave, sendo localizada a arma, carregador, munições e uma arma airsoft, salientando que o acusado confessou o crime perante a autoridade policial (arquivo digital- fl. 595).

No mesmo sentido o relato de seu colega JEFFERSON LUIS RIBEIRO CASSIANO, que confirmou que o indivíduo foi abordado em razão de denúncia, pois ele era procurado pela Justiça. No momento da abordagem, ele estava com o filho, motivo pelo qual foram até a residência dele deixar a criança com um responsável. O acusado confessou, de imediato, que havia uma arma em sua residência, indicando o caminho da casa e autorizando a entrada no local. Descreveu onde a arma estava guardada, qual seja, em um veículo na garagem, sublinhando que, no mesmo compartimento, foi localizada uma arma de airsoft, e em um micro-ondas próximo ao carro, munições (arquivo digital - fl. 595).

O laudo pericial realizado na arma de ar comprimido atestou que o simulacro de pistola, modelo 93A, marca Daisy, tipo arma de CO2 cl. 4,5mm, com cano de 140 mm, confeccionada em material plástico preto e metálico, apresenta semelhança com uma pistola verdadeira, podendo ser eficazmente utilizada como instrumento de intimidação na prática de roubo ou outro delito, ressaltando que a eficácia da referida peça não pode ser testada quanto ao disparo das munições de esfera em razão da ausência de munições e dispositivo do tipo cilindro de CO2 (fls. 140/142).

O laudo pericial de fls. 649/655 atestou a potencialidade lesiva da pistola Sarsilmaz, modelo Kilinç 2000 Mega, com numeração de série suprimida por atritamento, aparentemente por ação humana, concluindo que ela pode ser utilizada para realizar disparos, pois seus sistemas de percussão, ejeção e carregamento, testados experimentalmente, funcionam normalmente, bem como estarem íntegros os cartuchos que a acompanhavam.

Ora, à luz da prova oral, verifica-se ter havido fundada suspeita da prática de crime permanente a autorizar a diligência independentemente de mandado judicial, ex vi do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

De fato, os policiais foram taxativos em asseverar ter o réu, em abordagem policial na qual se constatou ser ele foragido, admitido a posse de arma em sua residência, confissão esta formalizada pelo próprio acusado na fase policial e em juízo.

Nessa direção a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o

flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso." (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 -DIVULG 09-05-2016 - PUBLIC 10-05-2016)

Como bem ressaltou Min. Gilmar Mendes, relator do julgado referido, em seu voto, "(...) do policial que realiza a busca sem mandado judicial não se exige certeza quanto ao sucesso da medida. Em verdade, dificilmente a certeza estará ao alcance da polícia. (...). Por estar a certeza fora do alcance, a legislação costuma exigir modelos probatórios bem mais modestos para medidas de investigação. Para busca e apreensão, por exemplo, o Código de Processo Penal exige apenas 'fundadas razões' - art. 240, §1º".

Lícita, portanto, a prova obtida.

No mais, a confissão do réu aliada às provas oral e pericial não deixam dúvidas acerca da existência e autoria delitivas.

Não comporta acolhimento a alegação da defesa de atipicidade da conduta (por inexistência de lesão ao bem jurídico e crime impossível por absoluta ineficácia do meio), considerando que, além da arma de ar comprimido, fora apreendida pistola cuja potencialidade lesiva fora atestada pelo laudo pericial de fls. 649/655, frisando-se que o presente crime é de perigo abstrato.

Finalmente, referido laudo pericial também atestou a supressão da numeração da arma de fogo ventilado, enquadrando-se a conduta, portanto, art. 16, §1º, IV, da Lei de Armas, não havendo falar-se em desclassificação para o tipo penal do art. 12 do mesmo diploma legal.

Presentes, portanto, todas as elementares do delito do art. 16, §1º, IV, da Lei de Armas, e ausentes excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do réu em suas penas é impositiva.

Resta fixar as reprimendas.

Os antecedentes serão valorados na segunda etapa, já que, ante a reincidência (processo nº 0028848-90.2015, da 1ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para as partes em 14.02.2018, fls.40/41), não podem ser levados em conta neste passo, sob pena de bis in idem.

Assim o teor da Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça.

A condenação anterior transitada em julgado referente ao processo nº 0768870-96.2008 da 5ª Vara Criminal local, cuja pena privativa de liberdade foi declarada extinta pelo cumprimento em 17.03.2015 (fl. 42 e fl. 53), não forja reincidência, na forma do art. 64, I, do Código Penal. Seria ilógico desconsiderar a condenação para efeito de reincidência e sopesá-la na análise dos antecedentes do acusado. De fato, o Direito Penal moderno não compactua com máculas perenes, vigendo, atualmente, o princípio da temporariedade dos antecedentes.

Assim a jurisprudência:

“(...) Decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes. Aplicação do princípio da razoabilidade.” (HC 110191, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-05-2013 PUBLIC 06-05-2013).

“EMENTA: PROCESSO CRIMINAL. Suspensão condicional. Transação penal. Admissibilidade. Maus antecedentes. Descaracterização. Reincidência. Condenação anterior. Pena cumprida há mais de 5 (cinco) anos. Impedimento inexistente. HC deferido. Inteligência dos arts. 76, § 2º, III, e 89 da Lei nº 9.099/95. Aplicação analógica do art. 64, I, do CP. O limite temporal de cinco anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, aplica-se, por analogia, aos requisitos da transação penal e da suspensão condicional do processo”(HC 86646, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Primeira Turma, julgado em 11/04/2006, DJ 09-06-2006 PP-00018 EMENT VOL-02236-02 PP-00217 RTJ VOL-00200-02 PP-00933 LEXSTF v. 28, n. 332, 2006, p. 406-414 RT v. 95, n. 853, 2006, p. 504-507 RMDPPP v. 2, n. 12, 2006, p. 83-88).

Saliento, por oportuno, não haver transitado em julgado o v. acórdão do Supremo Tribunal Federal acerca do tema 150, com repercussão geral, não sendo, por ora, vinculante.

Ademais, conforme documentos de fls. 152/580, a sentença condenatória proferida no processo de nº 1503237-56.2018, da 3ª Vara Criminal local (fl. 42), foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

A motivação, circunstâncias e consequências do crime foram as comuns à espécie.

Diante desse quadro, em que são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) é também o comum, motivo por que fixo a pena-base no mínimo legal, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, e art. 60 do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do réu.

Na segunda fase, a agravante da reincidência compensa-se pela atenuante da confissão espontânea, valioso meio de prova que confere ao julgador a certeza moral de uma condenação.

Aliás, a atual jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido, tendo a Corte Superior decidido a matéria em recurso especial submetido ao procedimento previsto no art.543-C, do Código de Processo Civil:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido"

(REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

À carência de circunstâncias alteradoras na terceira fase, ficam as reprimendas supracitadas definitivamente estabelecidas.

A despeito da reincidência, são ao acusado favoráveis as circunstâncias judiciais, pelo que o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, "b", e parágrafo 3º). Nessa direção o verbete da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalto que essa conclusão não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A reincidência do réu em crime doloso obsta a concessão do sursis (art. 77, I, do Código Penal), e a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, não sendo ela, ademais, socialmente recomendável in casu, valendo registrar se referir a recidiva a delito de roubo duplamente circunstanciado, inclusive com emprego de arma.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar CARLOS ALEXANDRE BURGARELLI LOURENÇO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, às reprimendas de 03 (três) anos de reclusão (regime inicial semiaberto), além de 10 (onze) dias-multa, o unitário no piso legal.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade. Em caso de recurso, será incontinenti expedida guia de execução provisória, a fim de que o sentenciado seja inserido no regime a que condenado.

Recomende-se onde se encontra.

Cumpra-se o art. 25 da Lei nº 10.826/03.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita (fl. 96).

Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

São José dos Campos, 31 de outubro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA